

0062738-78.2017.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernando Augusto Andrade Conceição

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/06/2022

... e momentos diferentes. Nestes termos:

Tráfico de entorpecentes e Associação para o tráfico -Agentes surpreendidos trazendo consigo, para fins de tráfico, 3.026,50 gramas de cocaína em pó e 1.448,7 gramas de maconha - Conjunto probatório desfavorável aos réus alicerçado em depoimentos policiais verossímeis demonstrando tanto o tráfico como a união estável ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

0062738-78.2017.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0062738-78.2017.8.26.0050

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO CASSIANO DE ARAUJO e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Augusto Andrade Conceição

Vistos.

Rogério Romão e Thiago Cassiano de Araújo, qualificados nos autos nas fls. 26/27, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei nº. 11.343/06, c.c. artigo 69, do Código Penal, porque no dia 18/julho/2017, por volta das 08h50, na Travessa Manhã de Carnaval, altura do nº 86, nesta comarca, teriam se associado para, reiteradamente ou não, praticarem crime de tráfico; consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de dia, local e hora, Rogério Romão e Thiago Cassiano de Araújo agindo em concurso e com identidade de propósitos, traziam consigo droga, ou seja, 865g de tetrahydrocannabinol, substância entorpecente vulgarmente conhecida como maconha, acondicionadas em 243

invólucros plásticos, 1,5g de haxixe, acondicionado em 5 invólucros plásticos, 24g de cocaína acondicionada em 48 eppendorf's, 23,8g de crack acondicionados em 119 eppendorf's, 03 LSD's, e 05 frascos contendo lança-perfume, para consumo de terceiros, se autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Consta na denúncia que, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, ponto conhecido pela venda de drogas, quando avistaram os indiciados sentados na via em posse de uma sacola plástica e fazendo contagem de substâncias entorpecentes; em razão disso, decidiram aborda-los; no momento em que os indiciados notaram a aproximação dos policiais, tentaram se desfazer da sacola plástica e empreender fuga, porém foram por eles impedidos; em revista pessoal, os policiais localizaram em posse de Thiago um pedaço de papel contendo anotações referentes à traficância; além disso, os policiais localizaram junto aos indiciados 03 fragmentos de papéis coloridos de LSD, 05 frascos de lança-perfume, 243 invólucros plásticos contendo maconha, 48 pinos de cocaína, 119 eppendorf's de crack e 05 invólucros plásticos contendo haxixe.

A denúncia (fls. 185/186) veio acompanhada do Inquérito Policial (fls. 02/62), sendo a peça acusatória recebida em 10/agosto/2017 (fls. 187/188). Após a necessária notificação/citação (fls. 196 e 202/203), os réus apresentaram suas respostas à acusação (fls. 198 e 213),

Durante a instrução foram ouvidas quatro testemunhas (áudio sistema SAJ e audiência virtual sistema Teams) e os denunciados interrogados ao final (áudio - audiência virtual sistema Teams).

Nas suas considerações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação nos exatos termos da denúncia (fls. 301/305); a Defesa do réu Rogério pugnou pela absolvição (fls. 309/317); a Defesa do denunciado Thiago requereu a absolvição de ambos os delitos ou, em caso de condenação, pela fixação da pena base no mínimo legal, aplicação do redutor do parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, aplicação de regime aberto para cumprimento de pena, além da substituição por restritiva de direitos, bem como a possibilidade de recorrer em liberdade (fls. 319/328).

O Laudo de Constatação Prévia encontra-se nas fls. 21/23; o de Exame Químico Toxicológico nas fls. 207/212 e o Auto de Exibição e Apreensão das substâncias entorpecentes está nas fls. 17/18.

É o relatório.

Decido.

Ao término da instrução, verificou-se que os fatos narrados na exordial restaram parcialmente comprovados, razão pela qual a ação deve ser julgada a favor da Justiça Pública em parte.

Interrogado em Juízo, o acusado Rogério Romão, 24 anos, negou a acusação; estava indo trabalhar quando foi buscar maconha; chegou primeiro e Thiago logo em seguida; a ROCAN chegou e o traficante fugiu, abordando os dois; não é verdade que foram flagrados contando droga; na verdade, quem estava contando a droga espalhada no chão era o traficante que fugiu quando a Rocam chegou (áudio sistema SAJ).

O denunciado Thiago Cassiano de Araújo, 33 anos, negou a acusação; estava descendo a rua quando viu uma pessoa no chão contando drogas; foi até lá pegar entorpecentes; o traficante correu e se escondeu dentro de uma casa, sendo o interrogando e Rogério presos; não é verdade que estava com um papel relativo a contabilidade do tráfico (áudio sistema SAJ).

Vejamos a prova do contraditório.

A testemunha Rafael Artur Ximenez, policial militar, disse recordar dos réus presentes; eles estavam em um escadão, conhecido ponto de tráfico; estavam fazendo contagem de entorpecentes; quando o depoente foi fazer a abordagem eles correram; o parceiro conseguiu fazer a abordagem; eles faziam a contagem para iniciar a venda; não recorda com qual deles estava; havia maconha, cocaína e crack; não recorda se tinha haxixe; havia pouca quantidade de LSD e tinha lança-perfume; não havia dinheiro com qualquer deles; já fez apoio a outras viaturas; os fatos foram pela manhã; ali só havia os dois; no momento eles confessaram a traficância; um deles morava nas proximidades, era o Thiago; as drogas estavam no chão e eles estavam sentados um de frente ao outro; havia um papel com anotações da contagem; disseram

que era a contagem inicial, pois iam começar o serviço; a sacola estava no meio dos dois; não fizeram campana prévia; sobre o local, há denúncias diretas (áudio sistema SAJ).

O depoente Jonathan Oliveira Valverde, policial militar, disse que, em patrulhamento de rotina, local conhecido pela venda de drogas, verificou dois rapazes no escadão com uma sacola e fazendo a contagem das drogas; abordados, eles tentaram fugir, mas foram presos; eles tentaram se desfazer da sacola contendo drogas (havia maconha, cocaína, LSD, crack e lança perfume); os dois confessaram informalmente a mercância ilícita; com Thiago encontrou papel contendo a contabilidade (áudio sistema SAJ).

A testemunha Edgar Alves da Silva, arrolada pela defesa de Rogério, disse conhecer Rogério há 10 anos; moram próximos; ficou sabendo da prisão, mais não viu; ele namora uma moça e mora com a mãe e a esposa; ele tem um filho; ele trabalha em um lava-rápido; nunca viu ele fazer nada de errado; ficou surpreso com essa situação (fl. 227 - áudio sistema SAJ).

O depoente Gilson José dos Santos, também arrolado por Rogério, disse conhecer o réu há 15 anos, moram perto; não viu a prisão dele; ele mora com a esposa e o filho; na casa debaixo mora a mãe; ele trabalha em um lava-rápido; não sabe se tem problema com droga; não sabe de ligação dele com ilícitos; nada sabe que o desabone (fl. 227 - áudio sistema SAJ).

Como se vê, a oitiva das testemunhas presenciais, somadas ao Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão, Laudo de Constatação Prévia e Exame Químico Toxicológico, tudo aponta no sentido de que a versão apresentada pela acusação é a verdadeira, eis que encontra simetria com as demais provas dos autos.

Com suas condutas, os réus se enquadram em, pelo menos, um verbo do tipo previsto no artigo 33 da lei especial: trazer consigo.

Destarte, verifica-se que a ação penal procede em parte.

De fato, os depoimentos dos policiais foram claros, serenos e seguros, dando conta da apreensão em poder dos acusados, de razoável quantidade de substância entorpecente, o suficiente a denotar o intuito da traficância.

A materialidade está estampada no Boletim de Ocorrência (fls. 11/16), no Auto de Exibição e Apreensão (fls. 17/18), no Auto de Constatação Prévia (fls. 21/23) e no Exame Químico Toxicológico (fls. 207/212).

Este último demonstra que as substâncias apreendidas realmente eram cocaína e maconha.

Em que pese à insurgência da Defesa, a traficância restou devidamente caracterizada e comprovada.

Como visto, os depoimentos dos policiais ouvidos em Juízo são coerentes e harmônicos e traduzem a certeza de que os réus, efetivamente, traziam com eles, dentro de uma sacola, razoável quantidade de cocaína e maconha, quando foram flagrados pelos agentes.

Portanto, restou claro que os policiais prenderam os acusados em flagrante em plena conduta típica, apreendendo em seu poder toda a cocaína e maconha encontrada.

Bem sabemos, como já dito acima, que incide nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, aquele que é detido com expressiva quantidade de substância tóxica.

No caso concreto, a droga estava sendo trazida, para entrega a consumo de terceiros, pelos acusados em local conhecido pela traficância, instante em que foram abordados por policiais militares, o que configura tráfico e não uso de drogas.

Assim, uma vez que os réus foram surpreendidos tendo consigo substância entorpecente, não se pode falar em guarda para consumo próprio, com a consequente desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06, mas sim em tráfico ilícito.

Certo é que, a só quantidade de droga, ainda que razoável, não define, por si só, a condição de traficante. Mas no presente caso, verifica-se que os réus foram flagrados trazendo consigo toda a cocaína e maconha apreendidas dentro de uma sacola.

É sabido que se tem reiteradamente decidido que para a caracterização do delito previsto no artigo 33, não se faz necessário seja o infrator colhido no próprio ato

da venda da mercadoria proibida. Tratando-se de crime de mera conduta, ter em depósito, guardar, transportar, trazer consigo, não importa a modalidade, forçoso reconhecer-se à configuração do crime em tela.

Ademais, por importante, mister se faz atentar para a natureza e a quantidade da substância apreendida (865g de maconha, 1,5g de haxixe, 24g de cocaína e 23,8g de crack, além de LSD e lança-perfume), o local (dentro de uma sacola) e as condições em que se desenvolveu a atividade delituosa (policiais militares em patrulhamento visualizaram os réus em um escadão, local conhecido pela traficância, no momento em que faziam a contagem dos entorpecentes, ocasião em que foram detidos).

Outrossim, não há que desmerecer os depoimentos dos policiais - ouvidos como testemunhas - tão só pelo fato de serem eles integrantes da Polícia.

Tal significaria preconceito odioso e inaceitável, caracterizando mesmo clara discriminação profissional que não tem qualquer respaldo jurídico.

Observe-se que, a Defesa nada comprovou contra a honradez e honorabilidade dos policiais ouvidos como testemunhas neste processo, nem mesmo que tivessem eles qualquer razão escusa para pretenderem prejudicar os acusados.

Assim, seus depoimentos não de ser prestigiados, em especial porque apresentam contornos de verossimilhança, estão conforme o conjunto das provas e, ademais, como já dito, são coerentes entre si, formando um todo harmônico e lógico.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de entorpecentes - Recurso da defesa - Preliminar de cerceamento de defesa - Inocorrência - Rejeitada - Absolvição - Materialidade e autoria demonstradas - Acusada surpreendida mantendo em depósito drogas para imediata distribuição - Depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela diligência - Validade - Contradições insignificantes e incapazes de ensejar a absolvição - Pena base alterada, mas sem reflexo na pena final - Redutor negado, mercê da expressiva quantidade de drogas apreendidas - Regime mantido em razão da gravidade da conduta - Apelo improvido. (TJSP; Apelação Criminal 1501099-78.2020.8.26.0567; Relator (a): Fernando Torres Garcia; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sorocaba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/02/2021; Data de Registro: 15/02/2021)

APELAÇÃO - Tráfico ilícito de drogas, dano qualificado e resistência em concurso material - Autoria e Materialidade comprovadas - Palavra dos Policiais Militares - Validade - Precedentes - Circunstâncias fáticas que demonstram o comércio ilícito de drogas realizado pelo réu - Laudos periciais corroborando a ocorrência dos delitos de resistência e dano qualificado - Incabível a alegação de insuficiência probatória - Pena - Dosimetria - Pleito de reconhecimento do redutor - Atendimento - Impossibilidade - Circunstâncias do caso concreto que indicam que o acusado se dedicava a atividades criminosas, no caso, ao tráfico habitual de drogas - Penas de todos os delitos fixadas de maneira apropriada - APELO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1501890-92.2018.8.26.0510; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Rio Claro - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/02/2021; Data de Registro: 15/02/2021).

Não se pode negar valia aos depoimentos dados pelos policiais nestes autos, pois, repita-se, produzidos de forma segura e extreme de dúvidas.

Como já dito, não há sequer sugestão de que tivessem eles o mínimo interesse em incriminar os acusados injustamente, mormente diante do notório risco de eventual responsabilidade pelo crime de abuso de autoridade ou de denúncia caluniosa. Além disso, pequenas divergências em seus depoimentos não tornam a prova frágil, vez que são inúmeros flagrantes por dia e, também, o local conhecido pela traficância e muitos flagrantes no local. Ainda, os réus, em uma primeira oportunidade, quando ouvidos na delegacia de polícia, tiveram a oportunidade de alegar inocência e nada disseram; se realmente fossem inocentes já teriam lá bradado a negativa de autoria.

As testemunhas de defesa do acusado Rogério em nada o socorreram, pois não presenciaram o flagrante; trouxeram informações sobre seus antecedentes.

Por fim, com relação ao delito previsto no artigo 35, não há prova nos autos de que os acusados teriam se associado, de modo estável e permanente, para praticar, naquele dia, a venda de entorpecentes, situação que afasta a configuração do crime em tela.

Neste sentido:

Apelação. Tráfico e associação. Art. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06. Preliminar de nulidade pela ilicitude da prova e cerceamento de defesa. Quanto ao mérito, pedido de absolvição pela insuficiência de provas, de desclassificação delitiva para porte para consumo, de incidência da atenuante da menoridade penal relativa e de reconhecimento da figura privilegiada, em relação a Andreza, de modificação do regime carcerário para outro menos severo e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em relação a André. Preliminares afastadas. Materialidade e autoria comprovadas em relação ao crime de tráfico, somente. Absolvição em relação ao delito de associação. Art. 386, VII, do CPP. Ausência de provas da estabilidade e permanência. Penas reduzidas. Regimes mantidos, pois bem fixados e fundamentados. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1501709-09.2019.8.26.0526; Relator (a): Reinaldo Cintra; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Salto - 2ª Vara; Data do Julgamento: 26/07/2020; Data de Registro: 26/07/2020)

Apelação Criminal - Tráfico de drogas - Sentença condenatória pelo art. 33, caput, e § 4º, da Lei 11343/06 - Absolvição do artigo 35, da Lei 11343/06, nos termos do artigo 386, VII, do CPP. Recurso da defesa -Preliminares - Nulidades- Prisão efetuada por Guardas Municipais - Inviolabilidade domiciliar - Interrogatório realizado por videoconferência- Preliminares afastadas - Nulidades inexistentes ao caso concreto- Mérito- Absolvição por falta de provas - Descabimento- Autoria e materialidade comprovadas - Negativa isolada nos autos - Firmes e coerentes relatos dos agentes públicos que participaram da diligência - Conjunto probatório seguro e coeso - Desclassificação para uso - Alegação desvinculada do conjunto probatório- Apreensão de grande quantidade de maconha e cocaína, além de petrechos para o tráfico de drogas- Desnecessidade de prova da mercancia, diante das diversas condutas previstas no art. 33, da Lei de Drogas -Condenação de rigor. Associação para o tráfico - Absolvição mantida -"Animus associativo" não configurado Dosimetria que não comporta reparos:Pena-base fixada no mínimo legal - Na segunda fase, nada foi considerado - Na derradeira etapa, incabível a aplicação do redutor de pena, diante das circunstâncias fáticas, que denotam dedicação à atividade criminosa - Regime inicial fechado mantido- Necessidade de resposta estatal mais enérgica na repreensão do delito- Sentença mantida - Apelos improvidos. (TJSP; Apelação Criminal 0022850-68.2017.8.26.0320; Relator (a): José Vitor Teixeira de Freitas; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Limeira - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/07/2020; Data de Registro: 08/07/2020)

Ante o exposto, conclui-se que o contexto probatório é harmônico e coerente; robusto o bastante a embasar a expedição de um édito condenatório.

Os réus realizaram conduta antijurídica que se subsume em tipo penal e, ante as suas culpabilidades, impõe-se a condenação e as penas que passo a dosar, eis que em seus benefícios não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

DOSIMETRIA

Prevê o art. 68 do Código Penal que a pena base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste código (circunstâncias judiciais); em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes (art. 65) e agravantes (arts. 61 e 62); por último, as causas de diminuição e de aumento, entendidas estas últimas como sendo os fatores de acréscimo ou redução da pena, assinalados em quantidades fixas (dobro, metade etc) ou em limites (um a dois terços etc), previstos na parte geral ou especial do Cód. Penal (cf. Código Penal Comentado, Celso Delmanto, 2ª ed. Renovar, p.120).

Já o art. 59 dispõe que o Juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e

consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime: as penas aplicáveis dentre as cominadas; a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos; o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade e a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

Prevê o artigo 42 da Lei nº. 11.343/06: O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Réu Rogério

O acusado é primário (fls. 241/242).

Sua culpabilidade, entendida como índice de reprovabilidade de sua conduta, no caso, é de média intensidade.

Sua personalidade e conduta social não de ser tidos por média intensidade.

Atento, ainda, ao motivo do delito - qual seja, o ânimo de auferir lucro, já que se dispuseram a trazer a droga no meio da rua - bem como, atento às circunstâncias e funestas consequências da infração, que degrada a pessoa e compromete o tecido social e, em especial, considerando a grande quantidade de substâncias entorpecentes que os acusados traziam com eles, com os malefícios de todos conhecidos, fixo a pena base 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, chegando a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa.

A pena base foi fixada acima do mínimo legal, em razão da enorme quantidade de drogas apreendidas, que certamente atingiriam um grande número de pessoas, com consequências devastadoras à sociedade, providência que encontra amparo no art. 42, da Lei nº 11.343/06.

Colaciono jurisprudência no sentido da possibilidade de exasperação da pena base em virtude da quantidade de drogas:

Tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas - Recursos defensivos - Pedidos de absolvição, sob o argumento da insuficiência de provas - Pedidos subsidiários, da defesa de ALLAN, de redução das penas e de diminuição ou isenção da pena pecuniária em razão da sua precária situação econômica - Autoria e materialidade bem demonstradas em relação a ambos os acusados, no tocante aos dois delitos - Penas-base majoradas em face da grande quantidade de maconha apreendida (3.489,42g) - Dosimetria das penas que não comporta alteração nesta Sede, eis que levada a efeito mediante boa ponderação dos critérios da lei em vigor - O valor estipulado a título de sanção pecuniária, correspondente ao mínimo previsto na lei em vigor, não comporta redução por falta de amparo legal - Prisão cautelar do apelante ODAIR que fica mantida, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Diretas de Constitucionalidade de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no acórdão. Recurso desprovido.(TJSP; Apelação Criminal 1500849-35.2018.8.26.0302; Relator (a): Otavio Rocha; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jaú - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/02/2021; Data de Registro: 01/02/2021)

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade, efetuo a diminuição de 1/6 (um sexto), chegando a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, mais pagamento de 500 (quinhentos) dias multa.

O acusado faz jus à causa de diminuição prevista no parágrafo 4º, do artigo 33 da nova lei de entorpecentes, eis que é primário e possui bons antecedentes, devendo sua pena ser reduzida no patamar de ½ (metade), chegando-se a pena final de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias multa, a qual torno definitiva na ausência de outras modificadoras. Entende este juízo que, embora grande a quantidade de droga, não há qualquer outra prova nos autos que o acusado faça parte de organização criminosa ou exerça o ilícito habitualmente, razão pela qual o redutor deve ser aplicado, porém em grau

intermediário.
Neste sentido:

Apelação. Tráfico ilícito de entorpecentes majorado (artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06). Sentença condenatória. Defesa apela referendo a absolvição e o direito de apelar em liberdade. Autoria e materialidade devidamente fundamentadas. Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar o dolo da mercancia da ré. Confissão judicial corroborada pelos depoimentos dos policiais. Manutenção da condenação. Dosimetria comporta reparo. Basilar deve retornar ao mínimo legal. Confissão reconhecida, contudo, sem reflexo na pena. Súmula 231 do C. STJ. Reconhecimento do redutor previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas. Quantidade que, por si só, não afasta a aplicação do redutor. Ré primária. Não comprovação de envolvimento com atividades criminosas ou organização criminosa. Quantidade a impedir, todavia, a redução no patamar máximo, mostrando-se ajustada a redução de metade. Abrandamento do regime prisional para o aberto. Pena corporal substituída por restritiva de direitos. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.(TJSP; Apelação Criminal 1500680-42.2019.8.26.0616; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Suzano - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/02/2021; Data de Registro: 18/02/2021)

APELAÇÃO. Tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Recursos defensivo e ministerial. Insuficiência probatória. Não ocorrência. Autoria e materialidade bem demonstradas. Desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/06. Inviabilidade. Circunstâncias da prisão e quantidade de droga incompatíveis com a alegação de posse de drogas para consumo pessoal. Condenação confirmada. Dosimetria. Pena imposta pelo crime de posse irregular de arma de fogo corretamente mantida no piso. Pena-base relativa ao crime de tráfico fixada acima do mínimo legal. Quantidade da droga que deve ser considerada para aferição do redutor. Redução de rigor. Apelante primário, preso com quantidade de drogas não excessiva, sem demonstração de que se dedique a atividades ilícitas ou que pertença a organização criminosa. Circunstâncias favoráveis. Possibilidade de aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em seu grau intermediário, em face da quantidade e variedade das drogas, com fixação de regime aberto para o início do cumprimento da pena e conversão da pena privativa de liberdade em penas restritivas de direitos. Pretensão da concessão do direito de recorrer em liberdade prejudicada. Recurso ministerial improvido e recurso da Defesa parcialmente provido.(TJSP; Apelação Criminal 1500411-86.2020.8.26.0286; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itu - 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; Data do Julgamento: 16/02/2021; Data de Registro: 16/02/2021)

Ainda, no que diz respeito ao fator de redução, não há violação ao princípio do bis in idem, quando este subscritor utilizou-se da mesma regra – quantidade e natureza da droga – para dosar a redução em ½ (metade), haja vista ter se utilizado da mesma fundamentação em finalidades e momentos diferentes. Nestes termos:

Tráfico de entorpecentes e Associação para o tráfico –Agentes surpreendidos trazendo consigo, para fins de tráfico, 3.026,50 gramas de cocaína em pó e 1.448,7 gramas de maconha – Conjunto probatório desfavorável aos réus alicerçado em depoimentos policiais verossímeis demonstrando tanto o tráfico como a união estável e duradoura entre os acusados para a prática de tráfico – Descabimento da causa de redução prevista no § 4º, do art. 33 Lei n. 11.343/06 Ainda que as investigações tenham se iniciado em razão de meras denúncias anônimas, a condenação, tanto pelo crime de tráfico, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, como pelo de associação para o tráfico, descrito no art. 35 do mesmo estatuto repressivo, será de rigor, sempre que o conjunto probatório, alicerçado em depoimentos policiais verossímeis, demonstre de modo efetivo, não apenas a existência do tráfico ilícito de

entorpecentes, como de que este foi antecedido pela união estável e duradoura entre os acusados voltada para sua prática. Em tal situação é, ainda, incabível a incidência da causa de redução prevista no § 4º, do art. 33 do referido diploma legal, por incompatibilidade lógica, uma vez que a associação para o tráfico denota, com efeito, o envolvimento do agente com atividades criminosas e a integração de organização criminosa, aspectos que afastam a incidência da referida causa especial de diminuição de pena. Cálculo da Pena – Tráfico de entorpecentes – Quantidade e variedade de substância tóxica apreendida indicativa de maior potencial nocivo da conduta do agente – Circunstância objetiva que deve pesar tanto para majorar a pena-base como para simultaneamente justificar aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 em percentual abaixo do máximo – Inexistência de bis in idem O art. 42 da Lei n. 11.343/2006 determina que, na dosimetria da pena, sejam sempre considerados tanto a natureza e a quantidade de entorpecente, quanto a personalidade e a conduta social do agente. A incidência do primeiro fator mencionado, de ordem qualitativa e quantitativa, não só pode – como deve – ocorrer, tanto na primeira fase do cálculo da pena, como também cumulativamente na terceira, na qual será fixado o percentual de eventual redução, na hipótese de estarem presentes os requisitos do art. 33, § 4º, do mesmo diploma legal. Assim, ainda que a pena-base já tenha sido majorada com lastro na quantidade e na variedade do tóxico apreendido, poderá perfeitamente o Magistrado, com base no mesmo fundamento, deixar de aplicar o redutor em seu máximo, e estabelece-lo em patamar mínimo ou intermediário, sem que tal proceder implique em bis in idem; isso porque referido elemento qualitativo e quantitativo será necessariamente apreciado em cada fase do cálculo sob perspectivas completamente distintas. Na primeira fase, a quantidade e a variedade da substância apreendida devem ser consideradas, com efeito, enquanto parâmetro para a constatação da intensidade de lesão à saúde pública; na terceira, enquanto fator de aferição do grau de envolvimento do réu com a criminalidade organizada ou de sua devoção à atividade criminosa. (TJSP; Apelação Criminal 0012004-89.2018.8.26.0050; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 21ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/01/2021; Data de Registro: 29/01/2021)

Réu Thiago

O acusado é primário (fls. 243/244).

Sua culpabilidade, entendida como índice de reprovabilidade de sua conduta, no caso, é de média intensidade.

Sua personalidade e conduta social não de ser tidos por média intensidade.

Atento, ainda, ao motivo do delito - qual seja, o ânimo de auferir lucro, já que se dispuseram a trazer a droga no meio da rua - bem como, atento às circunstâncias e funestas consequências da infração, que degrada a pessoa e compromete o tecido social e, em especial, considerando a grande quantidade de substâncias entorpecentes que os acusados traziam com eles, com os malefícios de todos conhecidos, fixo a pena base 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, chegando a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa.

Na segunda fase não há agravantes ou atenuantes a considerar.

O acusado faz jus à causa de diminuição prevista no parágrafo 4º, do artigo 33 da nova lei de entorpecentes, eis que é primário e possui bons antecedentes, devendo sua pena ser reduzida no patamar de ½ (metade), chegando-se a pena final de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mais pagamento de 291 (duzentos e noventa e um) dias multa, a qual torno definitiva na ausência de outras modificadoras.

Cada dia multa fica fixado no valor mínimo previsto na lei especial, dada a pouca fortuna do réu, dado que emerge dos autos.

Atento a primariedade dos acusados, além da quantidade de pena imposta, fixo o regime aberto para cumprimento de pena.

Anoto que, este posicionamento, neste caso, partiu da necessidade de proporcionar ao réu uma nova oportunidade, pois não adianta somente castigar o indivíduo; retirá-lo do convívio da sociedade e de seus familiares, da possibilidade de

conseguir sustentar-se e encarcerá-lo novamente gerará uma revolta; a descrença na justiça será enorme; sua não reinserção na sociedade fará com que acabe praticando novas infrações e, atolando ainda mais o sistema carcerário.

DECISÃO.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA DEDUZIDA EM JUÍZO e o faço para declarar os réus:

Rogério Romão, qualificado nos autos na fl. 26, incurso no artigo 33, caput, c.c. parágrafo 4º, da Lei 11.343/06, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias multa, cada qual no valor mínimo legal, ante a pouca fortuna do condenado, dado emergente dos autos;

Thiago Cassiano de Araújo, qualificado nos autos na fl. 27, incurso no artigo 33, caput, c.c. parágrafo 4º, da Lei 11.343/06, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mais pagamento de 291 (duzentos e noventa e um) dias multa, cada qual no valor mínimo legal, ante a pouca fortuna do condenado, dado emergente dos autos;

pelos fundamentos acima, ABSOLVO Rogério Romão e Thiago Cassiano de Araújo da prática do delito previsto no artigo 35, da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Preenchendo os acusados os requisitos do artigo 43 e seguintes do Código Penal, converto suas penas privativa de liberdade em duas restritivas de direitos, quais sejam, uma prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas a critério do Juízo das Execuções Criminais, mais pagamento de 10 (dez) dias multa.

Neste sentido:

APELAÇÃO - Tráfico de drogas - Apelo do Ministério Público desprovido - Quantidade de entorpecente apreendida que não pode ser considerada expressiva, razão pela qual a pena-base deve ser mantida no mínimo legal - Ausente prova de que o réu se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa - Cabível o reconhecimento do chamado tráfico privilegiado, com a redução da pena, em sua fração máxima (2/3), nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 - Viável a substituição da reclusiva por duas penas alternativas, consistentes em prestação de serviços comunitários e outra multa - Também deve ser modificado o regime inicial para o aberto, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do CP - Precedentes do C. STJ e do E. STF - APELO DO MP DESPROVIDO - RECURSO DEFENSIVO PROVIDO para reduzir as penas a 01 ano e 08 meses de reclusão, além de 166 dias-multa, bem como para modificar o regime para o aberto, substituindo-se a reclusiva por penas restritivas de direitos - Expeça-se, com urgência, alvará de soltura clausulado. (TJSP; Apelação Criminal 1500317-90.2018.8.26.0551; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Limeira - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/07/2020; Data de Registro: 10/07/2020)

Tráfico de drogas. Conduta de trazer consigo, expor à venda e guardar 46 porções de cocaína. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Pretendida absolvição. Inadmissibilidade. Depoimentos de policiais militares que efetuarão a prisão. Usuário surpreendido no momento da abordagem que afirmou ter adquirido entorpecente do réu. Validade e suficiência para a procedência da ação penal. Circunstâncias da prisão e modo de acondicionamento indicativos do intuito mercantil. Condenação mantida. PENA. Majorante referente à proximidade de igrejas e estabelecimentos de ensino que não pode ser mantida. Absoluta ausência de indicativos no sentido de que a traficância colocava em risco os seus frequentadores. Redução para 1 ano e 8 meses de reclusão, e 166 dias-multa. Substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos. Admissibilidade. Inconstitucionalidade das vedações da Lei 11.343/06. Violação ao princípio da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da CF). Precedentes do STF e do STJ. Conversão da pena reclusiva em restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. Inteligência do artigo 44, § 2º, parte final, do CP. Imposição do regime aberto. Apelo defensivo parcialmente provido para esse fim. (TJSP; Apelação Criminal 0000271-94.2017.8.26.0557; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª

Câmara de Direito Criminal; Foro de Barretos - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/07/2020; Data de Registro: 08/07/2020)

Nos termos do artigo 63, caput e §1º, da Lei 11.343/2006, determino, se for o caso, o perdimento do valor apreendido em favor da União.

Deixo de determinar o lançamento do nome dos réus no rol dos culpados, ante a revogação do artigo 393, do Código de Processo Penal.

Nos termos do artigo 72 da Lei 11.343/06, determino a destruição das drogas armazenadas para contraprova, no prazo máximo de 30 dias, devendo a autoridade policial enviar termo da incineração.

Por fim, deixo de condenar o réu Thiago ao pagamento de custas processuais, por ser ele beneficiário da gratuidade judiciária, vez que assistido pela Defensoria Pública.

Por fim, condeno o réu Rogério ao pagamento das custas processuais em seu mínimo legal (Lei Estadual de Custas), pois se encontra assistido por defensor constituído, presumindo-se, assim, relativa capacidade econômica para arcar com tal finalidade.

P . I . C .

São Paulo, 13 de junho de 2022.

Fernando Augusto Andrade Conceição

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006.